Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
5ª Vara Cível

Autos n° 0812841-83.2020.8.12.0001
Ação: Procedimento Comum Cível
Requerente e Autor: Edson Fernando da Silva e outros
Réu: Unimed Seguros Sáude S/A

SENTENÇA
I - RELATÓRIO

POLIANA DA CRUZ, ANA CAROLINA CRUZ DA SILVA SOUZA e HELOISA CRUZ DA SILVA, ambas incapazes e representadas pela primeira autora, sucessoras de EDSON FERNANDO DA SILVA, todas com qualificação nos autos, propuseram **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA (LIMINAR) c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS** em face de **UNIMED SEGUROS SÁUDE S/A**, também com qualificação nos autos, formulando os seguintes pedidos:

> ***" seja julgada PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, e, como consequência, a confirmação definitiva da tutela de urgência para compelir a Requerida ao custeio de todo tratamento oncológico que o Requerente necessita, especialmente o fornecimento da quimioterapia com as drogas Bendamustina + Polatuzumabe Vedotin, conforme prescrição médica, ou quaisquer outros que venham a ser prescritos;***
>
> ***Requer, também, a condenação da Requerida ao pagamento de indenização para compensação dos danos morais causados ao Requerente, no valor a ser arbitrado por***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 08/08/2023 às 11:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0812841-83.2020.8.12.0001 e código M1qp7oET.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
5ª Vara Cível

Vossa Excelência, mas que sugere não seja inferior a R$ 30.000,00 (trinta e cinco mil reais), valor que representa menos do que 5% (cinco por cento) do valor da causa, sem esquecer do real poder econômico da Requerida e do dano que vem causando ao Requerente; ".

Como causa de pedir, sustenta que EDSON FERNANDO DA SILVA é beneficiário do plano de saúde da parte requerida.

Esclareceu que o mesmo foi diagnosticado como portador de câncer "Linfoma Não Hodgkin Difuso de Grandes Células B" (CID 10 C83.3).

Relatou que seu médico optou seguir o tratamento com o uso dos medicamentos denominados Rituximabe (Mabthera), Bendamustina (Ribomustin) e Polatuzumabe Vedotina (Polivy), visto que tal medicação é indicada especificamente para câncer de natureza refratária, ou seja, que não apresentou resposta aos tratamentos anteriormente ministrados (Rádio ou Quimioterapia) e causa menos efeitos colaterais.

Afirmou que solicitou à parte requerida a autorização para a realização do tratamento nos termos solicitados pelo médico, no entanto, a requerida não autorizou toda a medicação, mas tão somente o medicamento Rituximabe (Mabthera), sustentando que o medicamento Bendamustina (Ribomustin) seria indicado para o caso de tratamento clínico ou cirúrgico experimental. Com relação ao terceiro medicamento, o Polatuzumabe (Polivy), a requerida preferiu solicitar ao médico do requerente um relatório complementar, justificando qual seria a contraindicação que o paciente apresenta para Transplante de Medula e, após o envio do relatório, informou que referido medicamento não pode ser comercializado no Brasil, uma vez que, embora devidamente registrado, a condição comercial ainda não foi estabelecida.

Aduziu que, após reunião com a empregadora do requerente, a requerida reconsiderou sua decisão e "autorizou" a compra de um dos medicamentos que anteriormente tinha negado, qual seja, o Polatuzumabe (Polivy), porém, manteve a negativa quanto à Bendamustina (Polivy).

Observou que os medicamentos então autorizados (Polatuzumabe – Polivy e Rituximabe – Ribomustin) são os de maior custo financeiro,

Mod. 990080506 - Endereço: Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - 3º andar - Bloco III - CEP 79002-919, Fone: 3317-3369, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 08/08/2023 às 11:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0812841-83.2020.8.12.0001 e código M1qp7oET.

entretanto, a compra desses medicamentos nunca aconteceu.

Por tais motivos, requereu a antecipação dos efeitos da tutela, aduzindo presentes os requisitos legais necessários ao seu deferimento, para a finalidade de determinar que a parte requerida autorize o tratamento nos termos solicitados pelo seu médico.

A tutela de urgência foi deferida na decisão de fls. 76/85.

Contra referida decisão a requerida interpôs agravo de instrumento, o qual não foi conhecido (fls. 210/216).

A parte ré foi citada (fl. 96), sendo que compareceu aos autos e ofertou contestação (fls. 139/163), alegando, em síntese o seguinte: 1) impugnação ao valor da causa; 2) impossibilidade de fornecimento do medicamento *polatuzu-mabe vedotin (polivy)* – processo de registro e precificação não concluído pela Anvisa; 3) medicamento não comercialização no Brasil; 4) impossibilidade de fornecimento do medicamento *benda-mustina (ribomustin)* – ausência de cobertura obrigatória – medicamento *off-label;* 5) refere que o o contrato firmado entre as partes atende explicitamente às respectivas regras, restando claro que é plenamente possível o estabelecimento de limitações; 6) ausência de conduta ilícita; 7) ausência de danos morais; e 8) pugna pelo julgamento improcedente da ação.

A parte autora impugnou os termos da contestação na manifestação de fls. 217/227.

A parte requerida informou que houve a suspensão dos referidos medicamentos - “Bendamustina (RIBOMUSTIN)” e “Polatuzumabe vedotin (POLIVY)”. em razão das reações adversas e ineficácia do tratamento, de modo que requereu a extinção do feito sem resolução de mérito (fls. 228/230).

Juntou documento à fl. 231 e gravação de áudio à fl. 232.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 08/08/2023 às 11:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0812841-83.2020.8.12.0001 e código M1qp7oET.

Às fls. 238/250, foi informado que o autor EDSON FERNANDO DA SILVA veio à óbito. Certidão de óbito à fl. 258.

Na manifestação de fls. 238/250, a parte autora ressaltou que a tese da parte requerida não se sustenta na medida em que se impõe a confirmação da tutela liminar específica da obrigação por sentença.

Foi designada audiência de conciliação, a qual restou sem êxito (fl. 325).

Na decisão de fls. 297/298, diante do falecimento do autor, foi deferida a sucessão processual da parte autora EDSON FERNANDO DA SILVA, pelos seus sucessores POLIANA DA CRUZ (cônjuge) e as filhas ANA CAROLINA CRUZ DA SILVA SOUZA e HELOISA CRUZ DA SILVA, ambas menores absolutamente incapazes, representadas por sua genitora POLIANA DA CRUZ.

O Ministério Público Estadual ofertou manifestação às fls. 305/306).

O feito foi saneado na decisão de fls. 338/34.

Em seguida, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público Estadual manifestou-se pela procedência do pedido de indenização por danos morais (fls. 378/385).

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.I – REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO

Na manifestação de fls. 228/230, a requerida pugnou pela extinção do feito, em razão da perda do interesse de agir, sustentando que o médico do autor suspendeu a utilização dos medicamentos aqui buscados - “Bendamustina (RIBOMUSTIN)” e “Polatuzumabe vedotin (POLIVY)” - em razão das reações adversas

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 08/08/2023 às 11:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0812841-83.2020.8.12.0001 e código M1qp7oET.

e ineficácia do tratamento. Juntou documento à fl. 231 e gravação de áudio à fl. 232.

Em que pese a manifestação da requerida, tal requerimento deve ser indeferido.

É fato incontroverso nos autos que a requerida negou os medicamentos dando causa ao ajuizamento da ação.

Ainda que no curso da ação o autor tenha apresentado reações aos mencionados medicamentos que motivaram a suspensão do uso, sabe-se que reações adversas são imprevisíveis e só poderiam ser observadas quando do uso de tais medicamentos.

Vale destacar que a suspensão de tais medicamentos (fl. 231) ocorreu no mesmo mês em que o autor veio à óbito (setembro/2020), o que faz concluir que o mesmo já apresentava um quadro de saúde muito grave à época.

Logo, ao contrário do alegado pela requerida, não há que se falar em extinção da ação.

II.II – OBRIGAÇÃO DE FAZER

Inicialmente, é importante destacar que a atividade de prestação de assistência médico-hospitalar está abrangida pelo Código de proteção e de Defesa do Consumidor, a teor do que disciplina do artigo 3.º, § 2.º, do CDC, corroborado pelo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado 469.

Em semelhantes litígios deve ocorrer a facilitação da defesa do consumidor em juízo e pode até ser determinada a inversão do ônus da prova, tudo nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, e com base na legislação consumerista, deve-se repelir do contrato firmado entre as partes toda e qualquer cláusula que implique em

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 08/08/2023 às 11:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0812841-83.2020.8.12.0001 e código M1qp7oET.

contrariedade à boa-fé e ao equilíbrio contratual.

Com isso, é possível afirmar que os direitos básicos do consumidor e as suas normas protetivas devem todas ser aplicadas no contrato em questão, principalmente o art. 6.º, V, que estabelece a possibilidade da quebra da base objetiva do contrato, excetuando, portanto, o princípio do *pacta sun servanda*.

É cediço que não cabe ao plano de saúde delimitar a espécie de procedimento ou tratamento que o paciente pode ter acesso, se este foi resultado de indicação médica, constituindo tal ato verdadeira cláusula abusiva, que afronta diretamente as normas protetivas previstas no art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

> ***"Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:***
>
> ***I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis***
>
> ***II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;***
>
> ***III - transfiram responsabilidades a terceiros;***
>
> ***IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;***
>
> ***VI - estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor;***
>
> ***VII - determinem a utilização compulsória de arbitragem;***
>
> ***VIII - imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor;***
>
> ***IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor;***
>
> ***X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;***
>
> ***XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor;***
>
> ***XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;***
>
> ***XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração;***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 08/08/2023 às 11:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0812841-83.2020.8.12.0001 e código M1qp7oET.

> ***XIV - infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais;***
> ***XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;***
> ***XVI - possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias".***

Dessa maneira, verifica-se que é obrigação do plano de saúde disponibilizar o tratamento médico adequado e que foi indicado pelo médico da autora, sendo que eventual limitação contratual a esse direito, conforme preceitua o artigo 51 do aludido Código, deve ser considerada nula.

Logo, constata-se que, via de regra, o tratamento médico adequado e que foi indicado pelo médico da autora, deve ser coberto pelo plano de saúde.

Nesse ponto aliás, a jurisprudência do E. STJ ***"reconhece a possibilidade do plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas."*** (AgRg no REsp 1325733/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016).

No mesmo diapasão, certamente diante da quantidade de demandas sobre a matéria, o E. TJ/SP editou as súmulas 96 e 102, que assim dispõem:

> ***"Súmula 96 - Havendo expressa indicação médica de exames associados a enfermidade coberta pelo contrato, não prevalece a negativa de cobertura do procedimento".***
>
> ***"Súmula: 102 - Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS".***

Também a jurisprudência do E. TJ/MS trilha no mesmo caminho, como se vê dos julgados a seguir transcritos, os quais foram colhidos entre muitos de igual teor:

> ***"E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA EM***

Mod. 990080506 - Endereço: Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - 3º andar - Bloco III - CEP 79002-919, Fone: 3317-3369, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 08/08/2023 às 11:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0812841-83.2020.8.12.0001 e código M1qp7oET.

PRIMEIRO GRAU – LIMITAÇÃO DE COBERTURA RELATIVA A TRATAMENTO RPG – AUSÊNCIA DE COBERTURA DO TRATAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE – CLAUSULA ABUSIVA – RELAÇÃO CONTRATUAL – COBERTURA DE FISIOTERAPIA – NÃO CABE AO PLANO DECIDIR QUAL MÉTODO E SIM AO MÉDICO – TUTELA CONCEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não cabe ao plano decidir qual tratamento deve ou não ser utilizado para recuperação da saúde de um paciente. 2. Uma vez disponibilizada a cobertura ela não pode dizer quais procedimentos, materiais ou técnicas serão utilizadas no tratamento da doença para a qual o contrato preveja cobertura" ([1]).

"E M E N T A – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SÍNDROME MIELODISPLÁSTICAS DO SUBTIPO ANEMIA REFRATÁRIA – DIREITO DO PACIENTE A RECEBER O TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO QUE O ACOMPANHA – URGÊNCIA DA MEDIDA PARA TRATAMENTO E CONTROLE DA PATOLOGIA QUE PROGRIDE COM POSSIBILIDADE DE ÓBITO – REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA DEVIDAMENTE COMPROVADOS – POSSIBILIDADE DE SER PROFERIDA DECISÃO MONOCRÁTICA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, VIII, DO CPC/2015 C/C 138, IV, DO RITJMS – AUSÊNCIA DE ARGUMENTO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA – RECURSO IMPROVIDO. Diante da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, como a prova inequívoca do direito e a verossimilhança das alegações acerca da necessidade do medicamento pleiteado, a decisão a quo deve ser mantida. Diante da autorização de se proferir decisões monocráticas, concedida pela junção dos artigos 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 com o art. 138, IV, do RITJMS, não há que se falar em nulidade. Quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, devendo ser mantido o decisum que negou provimento de plano ao recurso ante a jurisprudência dominante dos Tribunais pátrios" ([2]).

No presente caso, os documentos juntados às 44 e 49/50 comprovam ser o autor EDSON FERNANDO DA SILVA beneficiário de plano de saúde contratado com a parte requerida e que foi diagnosticado com câncer "Linfoma Não Hodgkin Difuso de Grandes Células B" (CID 10 C83.3).

Além disso, a necessidade do tratamento requerido pelo autor com o uso dos medicamentos "Bendamustina (RIBOMUSTIN)" e "Polatuzumabe vedotin (POLIVY)" restou demonstrado pelos laudos/formulários de fls. 45/48, sendo que à fl. 47 consta indicação prescrita pelo médico LUIZ HENRIQUE MASCARENHAS

[1] **TJMS**; Agravo de Instrumento - Nº 1406439-42.2017.8.12.0000 - Dourados Relator : Exmo. Sr. Des. Amaury da Silva Kuklinski, julgado em 25/07/2018.
[2] **TJMS**; Agravo Interno - Nº 2000334-79.2018.8.12.0900/50000 - Bela Vista - Relator – Exmo. Sr. Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, julgado em 25/07/2018.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 08/08/2023 às 11:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0812841-83.2020.8.12.0001 e código M1qp7oET.

MOREIRA (CRM/MS 2209), especialista na área de Hematologia deste Estado, nos seguintes termos:

> ***"(...) A nova biópsia, embora com material mais escasso, revelou LNHGCB.***
>
> ***(...) Sendo assim e devido a agressividade da doença, por tratar se de paciente jovem, economicamente ativo, solicito realizar esquema indicado para LNHGCB refratário, no caso a associação de Rituximabe + Bendamustina + Polatuzumabe. Essa última droga foi liberada para uso no Brasil pela ANVISA no último mês de dezembro".***

A parte autora afirma que recorreu ao seu plano de saúde, todavia, o pedido foi negado, sob a justificativa de que o tratamento não está previsto em contrato, tampouco, está incluso no rol de coberturas mínimas exigidas pela ANS, bem como que não se encaixa em situação de urgência/emergência.

Ademais, através dos documentos de fls. 50 e 66/74, o autor comprova que a parte requerida não autorizou o tratamento indicado pelo médico LUIZ HENRIQUE MASCARENHAS MOREIRA, ou seja, refugou o tratamento indicado pelo médico do autor.

A requerida, como dito, sustenta que tais tratamentos não estão inclusos no contrato celebrado com a autora, que não estão previstos no rol de coberturas mínimas exigidas pela ANS, bem como que não se encaixa em situação de urgência/emergência.

Em que pese a manifestação da parte requerida, tal tese não merece prosperar.

É cediço que, o contrato firmado pelas partes é de trato contínuo visando à prestação de serviços de assistência à saúde, de modo que, havendo previsão de cobertura para a doença que o paciente pode apresentar, como no presente caso, é justa a sua expectativa de cobertura para a busca do tratamento médico que lhe for recomendado.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 08/08/2023 às 11:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0812841-83.2020.8.12.0001 e código M1qp7oET.

Ressalta-se que a finalidade do contrato em questão, assim como a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, permite o reconhecimento de que a recusa pela requerida foi injusta.

Logo, é possível observar a importância e a necessidade/urgência da utilização do tratamento indicado pelo médico do autor, haja vista que ele já havia realizado outros tratamentos, sem êxito, bem como não poderia realizar o tratamento de transplante de medula óssea (fl. 47).

Além disso, recentemente a Lei 14.454/2022 alterou a Lei n.º 9656/1998 - Planos de Saúde, a fim de estabelecer que o rol da ANS não é taxativo, visto que tratamentos que possuem comprovação de eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico ou que existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais, devem ser cobertos pelos planos de saúde, conforme o disposto no art. 10, §§ 12 e 13 da Lei 9656/1998:

> ***"§12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)***
>
> ***§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)***
>
> ***I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)***
>
> ***II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)".***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 08/08/2023 às 11:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0812841-83.2020.8.12.0001 e código M1qp7oET.

Logo, considerando que o tratamento indicado ao autor não consta do rol da ANS, bem como que ficou comprovada a sua eficácia no caso, haja vista a melhora do quadro do autor após o início do tratamento, de modo que a rigor o autor possui sim o direito de receber do plano de saúde requerido o tratamento indicado.

Especificamente sobre os medicamentos indicados ao autor - "Bendamustina (RIBOMUSTIN)" e "Polatuzumabe vedotin (POLIVY)", a matéria posta a decisão já foi objeto de decisão em outros feitos, nos quais se reconheceu o dever do plano de saúde fornecer tais medicamentos, mesmo que não conste do rol de procedimentos da ANS, como se vê dos julgados a seguir transcritos, os quais referem-se especialmente sobre os medicamentos indicados ao autor:

> ***"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar à ré que, de imediato, autorize a realização do tratamento da autora com o medicamento Bendamustina (Ribomunstin), na forma prescrita pela equipe médica. A determinação de cumprimento em prazo exíguo se mostrou necessária diante da peculiaridade do caso, haja vista a imprescindibilidade de dar continuidade a quimioterapia no prazo previsto pelo médico assistente. Requisitos para a antecipação de tutela preenchidos pela parte autora, nos termos do art. 300 do CPC. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (V.31628)". ([3])***
>
> ***"TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde -Decisão que antecipou os efeitos da tutela, para determinar que a agravante custeasse o medicamento BENDAMUSTINA utilizado no tratamento quimioterápico da agravada considerado experimental (off label). Negativa de cobertura ilegal. Abusividade reconhecida. Inexistência de aprovação junto à ANVISA. Irrelevância. Não cabe à ré nem ao paciente a escolha do medicamento. Presença dos requisitos formais do art. 273 do CPC para a concessão da tutela antecipada. Correta fixação de multa diária para funcionar como meio coercitivo. Patamar razoável. Descabimento de prazo suplementar para a disponibilização do medicamento pela agravante. Descabida a exigência de caução para a concessão ou manutenção da tutela antecipatória. Decisão mantida. Recurso não provido". ([4])***
>
> ***"PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE LINFOMA NÃO HODGKIN FOLICULAR (OBINUTUZUMABE E BENDAMUSTINA). O E. STJ, em regime de recursos repetitivos (REsp 1712163/SP e REsp***

[3] **TJSP**; AI 2199998-51.2019.8.26.0000; Ac. 12939637; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Viviani Nicolau; Julg. 02/10/2019; DJESP 07/10/2019; Pág. 1869.

[4] **TJSP;** AI 2242400-89.2015.8.26.0000; Ac. 9083507; Sorocaba; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Moreira Viegas; Julg. 16/12/2015; DJESP 28/01/2016.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 08/08/2023 às 11:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0812841-83.2020.8.12.0001 e código M1qp7oET.

1726563/SP), estabeleceu que a negativa de cobertura é lícita apenas para as hipóteses de medicamentos não registrados ou autorizados pela ANVISA: "As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA" Medicamentos prescritos à autora registrados na ANVISA. Limitação de cobertura que não se estende ao medicamento devidamente registrado prescrito ao paciente de forma diversa daquela que consta na bula (off label). Cobertura devida. Ação procedente. V. acórdão mantido" ([5]).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. Fornecimento de remédios. Obinutuzumabe e bendamustina. Alegação da parte ré, agravante, de que o quadro clínico da paciente (linfoma folicular) não atende aos critérios previstos na bula do fabricante dos remédios requeridos pela autora, e que por isso seu tratamento seria off label ou experimental. Equívoco. Há expressa menção na bula da droga obinutuzumabe de que sua associação com bendamustina tem como finalidade o tratamento da doença da agravada. Dessa arte, não bastasse ambos os medicamentos possuírem registro junto à ANVISA, a associação entre ambos é prevista em bula e respaldada pela citada instituição reguladora para o tratamento da doença da agravada, o que deita por terra os argumentos da recorrente, ao menos nesta fase do processo. Decisão mantida. Recurso desprovido". ([6])

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. LEI Nº 9.656/1998. IRRETROATIVIDADE. RECUSA DE COBERTURA. SÚMULA N° 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. Segundo o entendimento desta Corte, os contratos de plano de saúde anteriores à vigência da Lei n° 9.656/1998 se submetem às normas do CDC para o fim de aferir eventual abusividade. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para cada uma delas. 3. É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerando essencial para preservar a saúde e a vida do paciente. 4. No caso, o tribunal de origem, com base nos elementos dos autos, interpretou o contrato de forma favorável à agravada, sendo inviável a alteração de suas conclusões na via eleita, haja vista a incidência da Súmula n° 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido" ([7]).

Ademais, o autor comprovou que todos os medicamentos aqui buscados estão registrados na ANSIVA, inclusive houve o recente registro do medicamento "polatuzumabe vedotina" (polivy), conforme fl. 48, bem como apresentou

[5] **TJS;**- APEL. Nº: 1129224-09.2016.8.26.0100- COMARCA: SÃO PAULO – 10/04/2019.
[6] **TJRJ;** AI 0033973-14.2018.8.19.0000; Nova Iguaçu; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Antonio Ibrahim; DORJ 11/09/2018; Pág. 193.
[7] **STJ-** AgRg no AREsp Nº 475.558/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 26/5/2015, DJe 2/6/2015.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 08/08/2023 às 11:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0812841-83.2020.8.12.0001 e código M1qp7oET.

explicações sobre suas respectivas indicações (fls. 51/56).

No que tange às alegações de fls. 228/230, vale lembrar que reações adversas a algum medicamento são imprevisíveis e que os documentos e áudio de fls. 231/132 (suspensão dos medicamentos em razão de reações pelo paciente) não bastam para concluir pela ineficácia de tais medicamentos.

Nesse contexto, a requerida não poderia negar o fornecimento dos medicamentos supramencionados posto que foram indicadas pelo médico responsável pelo acompanhamento da saúde da parte autora (fls. 47/48).

Portanto, comprovada a necessidade de utilização dos medicamentos, em que pese no curso da ação o autor tenha apresentado efeitos colaterais que motivaram a suspensão do tratamento em questão (fls. 231/232), o pedido de obrigação de fazer consistente em fornecê-los deve ser julgado procedente.

II.III – DANOS MORAIS

Para que exista o dever de indenizar, como é sabido, é necessário que estejam presentes os elementos da responsabilidade civil, tais sejam: ação ou omissão, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo.

Nesse sentido são as disposições dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil vigente, que, assim dispõem:

> ***"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".***
>
> ***"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".***

Logo, provada existência da ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que cause prejuízo a outrem, o responsável pela violação fica

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 08/08/2023 às 11:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0812841-83.2020.8.12.0001 e código M1qp7oET.

obrigado a reparar o dano causado.

No que pertine à caracterização do dano moral, são pertinentes as lições sempre atuais de Yussef Said Cahali "***Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral***;" ([8]).

Com efeito, as provas produzidas evidenciaram a necessidade do tratamento solicitado pelo médico do autor, mas houve falha na prestação de serviço, na contramão da função social do contrato e do âmago da sua essência.

A propósito, importante destacar o julgado do Tribunal de Justiça deste Estado, a seguir transcrito:

> ***"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR RECHAÇADA – TRANSPLANTE DE RIM – DIREITO AO REEMBOLSO DO TOTAL DAS DESPESAS – DANOS MORAIS DEVIDOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA, RECURSO CONHECIDOS, RECURSO DO PLANO DE SAÚDE NÃO PROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao código de Defesa do Consumidor, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas da forma mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). No caso específico, não há como negar a cobertura do total das despesas com o procedimento (transplante de rim), uma vez que definidos os valores de reembolso mediante critérios inespecíficos cujas informações não foram devidamente repassadas ao consumidor. (...) Na hipótese, restaram configurados os pressupostos necessários à configuração dos danos de ordem moral, porquanto a injusta recusa de cobertura de plano de saúde aumentou o sofrimento do segurado, que inegavelmente ficou abalado emocionalmente diante da recusa de cobertura para que realizasse a cirurgia que necessitava transplante de rim - procedimento essencial para o restabelecimento de sua saúde (...)" ([9]).***

Ressalta-se que tal recusa indevida da cobertura do plano de saúde, ocorreu em um momento delicado na vida do autor, causando-lhe diversos

[8] Dano Moral, ed. RT., 2000, p. 20.

[9] **TJMS.** Apelação n. 0800769-47.2015.8.12.0031, Caarapó, 3ª Câmara Cível, Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 12/12/2017, p: 18/12/2017.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 08/08/2023 às 11:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0812841-83.2020.8.12.0001 e código M1qp7oET.

transtornos.

Logo, a negativa à realização do tratamento indicado para o autor causou manifesto sofrimento desnecessário ao mesmo, de modo que o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado procedente.

Nesse contexto resta devidamente demonstrado o dano moral sofrido pelo autor, razão pela qual fixo o valor da indenização no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente adequado à gravidade objetiva do fato e do seu efeito lesivo, considerando ainda as condições sociais e econômicas das partes envolvidas.

O valor fixado deverá ser atualizado pela variação do IGPM-FGV, desde a data desta sentença, com fim de preservar-se ante a espiral inflacionária.

Observo que a atualização monetária não constitui um *plus* no débito, mas mera recomposição de valores ante à espiral inflacionária, sendo adequada a utilização do IGPM/FGV, posto que se trata de índice que reflete a efetiva variação do custo de vida.

Em relação ao termo inicial dos juros moratórios, nos termos da jurisprudência do STJ (Recurso Especial nº 903258/RS), o termo inicial dos juros de mora em reparação por danos morais deve ser a partir da fixação do valor da indenização.

O percentual dos juros moratórios deve corresponder a 1% (um por cento) ao mês, visto que se aplica ao caso disposto no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional (Enunciado 20 do CEJ).

III - DISPOSITIVO

Posto isso, nos termos da fundamentação supra e com respaldo nos arts. 422, 423 e 424, 186 e 927, todos do Código Civil, bem como arts. 6.º, VIII, e 7.º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, **JULGO**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 08/08/2023 às 11:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0812841-83.2020.8.12.0001 e código M1qp7oET.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
5ª Vara Cível

PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na petição inicial para as seguintes finalidades:

1) condenar a requerida em fornecer os medicamentos "Bendamustina (RIBOMUSTIN)" e "Polatuzumabe vedotin (POLIVY)", nos exatos termos solicitados pelo médico do autor;

Por reputar presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, **CONFIRMO** a decisão que deferiu a tutela de urgência às fls. 76/85.

2) condenar a requerida no pagamento de indenização por dano moral à parte autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O valor da indenização por danos morais deverá ser corrigido monetariamente pela variação do IGPM-FGV desde a data desta sentença, bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, também desde a data desta sentença.

Condeno a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte autora, os quais, à vista do grau de zelo do profissional, o local de prestação de serviço (atendimento na Comarca), a natureza e a importância da causa (média complexidade) e dos vários atos processuais praticados, fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 85, §2º, I a IV, do Código de Processo Civil).

Julgo resolvido o mérito da causa na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

P.R.I.
Campo Grande/MS, *data do sistema*.

Wilson Leite Corrêa
Juiz de Direito
Documento assinado digitalmente

Mod. 990080506 - Endereço: Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - 3º andar - Bloco III - CEP 79002-919, Fone: 3317-3369, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 08/08/2023 às 11:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0812841-83.2020.8.12.0001 e código M1qp7oET.